

0001031-37.2017.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... sabe dizer se ele tem envolvimento com tráfico de drogas.

Cláudia Bertoni Francisco Rossi, ouvida como informante por ser mãe de Leonardo, disse que não sabe nada relacionado ao tráfico, mas que há um tempo ficou sabendo que seu filho é usuário; só soube da droga apreendida depois que seu filho lhe contou que a tinha comprado. Afirmou que Leonardo é usuário de maconha e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001031-37.2017.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001031-37.2017.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1880/2017 -

Delegacia de Polícia de José Bonifácio, 322/2017 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu

LEONARDO ROSSI e ALEXANDRE DE ARAUJO BATISTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

ALEXANDRE DE ARAÚJO BATISTA (fl. 25) e LEONARDO ROSSI (fl. 19) foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fls. 146/148).

Isso porque, segundo consta, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 23h, na Praça Sebastião Pereira Lima, Rua Piratininga, Centro, nesta cidade e comarca, os acusados praticaram o ato de trazer consigo, para entrega a consumo, 20 microtubos plásticos Eppendorf contendo cocaína, pesando 18,66 gramas, e 6 invólucros plásticos pesando 26,40 gramas, contendo a substância entorpecente TETRAHIDROCANABINOL (THC), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Valdir Fialho e Arruda (fls. 3/4) e PM Renan Tavares Baldassa (fls. 5/6).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 106/107).

Os acusados foram notificados pessoalmente (fls. 183 e 244) e apresentaram defesa prévia (fls. 186/196 e 197/206), por defensores constituídos (fls. 377/379).

LEONARDO pediu a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e

arrolou as seguintes testemunhas de defesa: Maria Célia Muriana Rodrigues, Isoaldo Barbosa Lima Filho, Rogério Emygdio dos Santos e Cláudia Bertoni Francisco Rosso; ALEXANDRE negou a prática do delito, pediu absolvição e arrolou as seguintes testemunhas: Jeferson Silva de Oliveira, Grazielle Furtado de Jesus, Francisco Monteiro e Célia.

Recebida a denúncia (fls. 224/225), foi realizada audiência de instrução (fls. 405/406).

As partes apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 580/588), enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas (fls. 589/618 e 639/644).

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 30/32), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 3/10), auto de exibição e apreensão (fls. 33/34) e laudo pericial (fls. 38/40).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Policiais militares em patrulhamento pelo local, conhecido por ponto de venda de entorpecentes, avistaram os denunciados sentados no banco da praça. Ao perceber a aproximação da viatura policial LEONARDO ROSSI e ALEXANDRE DE ARAÚJO BATISTA saíram caminhando acelerados, em atitude suspeita.

Antes da abordagem policial ALEXANDRE DE ARAÚJO BATISTA dispensou um pacote com 20 microtubos plásticos "Eppendorf" contendo cocaína, e, 06 invólucros plásticos contendo a substância entorpecente TETRAHIDROCANABINOL (THC). Pacote localizado e apreendido pelos milicianos à distância de 2 metros do denunciado.

Durante a revista pessoal realizada em ALEXANDRE DE ARAÚJO BATISTA, o denunciado LEONARDO ROSSI fugiu, porém, foi apreendido alguns quarteirões de distância. Com ALEXANDRE os milicianos lograram êxito em localizar e apreender a quantia de R\$ 370,00 e, com LEONARDO ROSSI a quantia de R\$ 31,00.

Auto de exibição e apreensão acostado a fls. 25/26. Laudo de Constatação n.º 407.188/2017 (fls. 30/32).

Foram apreendidos (fls. 30/34):

- Em poder de Alexandre: 20 pinos contendo cocaína, resultando em peso bruto aproximado de 15,7 gramas, 06 invólucros plásticos contendo maconha, resultando em peso bruto aproximado de 22,5 gramas, e a quantia de R\$ 370,00 em dinheiro;
- Em poder de Leonardo: a quantia de R\$ 31,00 em dinheiro.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para:

1- cocaína nas amostras colhidas de vinte microtubos plásticos do tipo Eppendorf, dotados de tampa própria, encerrando porção de material sólido particulado, com massa líquida de 5,06 gramas;

2- tetrahidrocannabinol - THC nas amostras colhidas de seis invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais com massa líquida de 21,41 gramas.

A testemunha PM Valdir Filho de Arruda, afirmou que não se lembra de muitos detalhes da ocorrência, mas que se lembra bem do indivíduo que correu, que foi para a casa do avô e lá foi pego; afirmou que lembra que um dos indivíduos dispensou um pacote quando avistou os policiais. Não conhecia nenhum dos acusados. Não soube precisar qual dos acusados dispensou a droga; para capturarem o indivíduo que correu, entraram com a viatura na praça, em local destinado a pedestres, e foi próximo de um banheiro que o pacote com as drogas foi dispensado. Afirmou que os dois acusados estavam juntos e que, quando foi anunciada a abordagem, um deles correu e o outro permaneceu.

A testemunha PM Renan Tavares Baldassa narrou que faziam patrulha no local quando se depararam com os dois indivíduos sentados em um banco da praça e que, ao avistarem a viatura, ambos se levantaram e tentaram sair de forma apressada, o que desencadeou a abordagem. Ao iniciarem a abordagem, puderam ver que o acusado Alexandre dispensou ao solo um pacote que continha entorpecentes; durante a abordagem pessoal, ele mesmo encontrou com Leonardo a quantia de R\$ 31,00 em

espécie e, nesse momento, o acusado empreendeu fuga; afirmou, então, que saiu ao encalço dele por cerca de 4 quarteirões e o deteve. Quando o restante dos policiais o localizaram, traziam Alexandre, com quem haviam encontrado R\$ 370,00, salvo engano, também em espécie. Diante dos fatos, da confissão e da materialidade, conduziram os acusados à delegacia do município. Confirmou que foi Alexandre quem dispensou o pacote no chão e Leonardo quem empreendeu fuga. Disse que aos policiais os acusados confessaram a traficância, mas que não se recorda do que eles declararam na delegacia. Não conhecia nenhum dos acusados, sabia apenas que o ponto citado, o encontro da rua Piratininga com a rua Nove de Julho, é conhecido nos meios policiais pelo problema com tráfico de entorpecentes.

A testemunha Jeferson Silva de Oliveira narrou que não viu drogas nem a abordagem; no momento em que viu, Alexandre já havia sido colocado na viatura. Não soube dizer se os acusados mexiam com droga. Disse que antes estava com Alexandre na praça, que comeram um lanche e que subiram para a avenida para dar uma volta; quando voltaram, Alexandre foi de novo até o quiosque de lanche e do nada foi enquadrado, mas não viu o momento da abordagem porque ficou no meio da praça enquanto Alexandre estava no lanche, só viu quando este já estava sendo colocado dentro da viatura. Afirmou que não estavam com Leonardo; que Alexandre passou em sua casa para buscá-lo por volta das 20h; que tem amizade com ele há bastante tempo e que ele é uma pessoa tranquila. Sabe que Alexandre mora na Vila dos Pescadores e trabalha com pesca; estava a cerca de 50 metros de onde ocorreu a abordagem, e era noite.

A testemunha Grazielle Furtado de Jesus afirmou que não presenciou os fatos; só sabe que Alexandre, seu cunhado, havia brigado com a sua irmã na segunda-feira, que desde então estaria em sua casa, em José Bonifácio. Narrou que no sábado Alexandre veio até a cidade para conversar com sua irmã, mas elas haviam ido para o rancho; que Alexandre ligou para sua irmã para que ela fosse até a cidade para eles conversarem e ela não foi e que, quando sua irmã pediu para ele ir até lá, ele disse que não iria; quando souberam, Alexandre já havia sido pego pela polícia. Afirmou que Alexandre e sua irmã moram em Ubarana, que ele trabalha como pescador, tem dois filhos e é um bom pai; que a briga entre ele e sua irmã foi boba e que ele se relaciona normalmente com sua família. Não sabe dizer se Alexandre e Leonardo são amigos e, até onde sabe, Alexandre não faz uso de entorpecentes.

A testemunha Francisco Monteiro afirmou não saber nada sobre os fatos e que não os presenciou; afirmou que é amigo de Alexandre e que ambos são pescadores profissionais; que sabe que Alexandre mora na Vila dos Pescadores e que não tem nada a reclamar dele; sabe que ele tem esposa e dois filhos. Nunca viu Alexandre fazer uso de entorpecentes e, por isso, nada pode dizer a respeito. Relatou que, na semana em que Alexandre foi pego, havia dado a ele R\$ 400,00 referentes à compra de peixe.

A testemunha Maria Célia Muriana Rodrigues afirmou que os acusados haviam pedido lanche em seu quiosque, que estava muito movimentado, e que quando viu eles já estavam sendo abordados. Não sabe dizer se a polícia encontrou droga, só viu a polícia chamando os acusados para irem para fora do quiosque. Não viu e não sabe dizer se eles estavam envolvidos com tráfico no local. Afirmou conhecer Alexandre e Leonardo, que são clientes de seu quiosque faz tempo; afirmou que a polícia chegou pela Rua Piratininga e que os acusados não estavam juntos na ocasião; Alexandre estava tomando um refrigerante esperando seu lanche ficar pronto e Leonardo já havia sido chamado para pegar seu lanche, pois pedira primeiro. Via sempre Leonardo na loja de seu avô e ele sempre ia em seu quiosque pedir lanche; nunca viu qualquer atitude suspeita da parte dele. Relatou que tem o quiosque no mesmo lugar há uns 6 anos e sabe que as pessoas comentam que a praça é um ponto de tráfico de drogas. Sabe que Leonardo é de José Bonifácio, de família tradicional da cidade, mas não sabe de onde Alexandre é; disse que os dois vão sempre ao local, em horários diferentes, e que Alexandre inclusive ia com a família, a mulher e dois filhos, com a qual ficava sentado um bom tempo no local. Afirmou que os acusados sempre pagavam os lanches em dinheiro, pois ela não tem máquina de cartão.

A testemunha Isoaldo Barbosa Lima Filho afirmou que não presenciou os fatos; disse que conhece Leonardo desde que ele nasceu e que ele presta serviços em seu sítio; não sabe dizer se ele tem envolvimento com tráfico de drogas.

Cláudia Bertoni Francisco Rossi, ouvida como informante por ser mãe de Leonardo, disse que não sabe nada relacionado ao tráfico, mas que há um tempo ficou sabendo que seu filho é usuário; só soube da droga apreendida depois que seu filho lhe contou que a tinha comprado. Afirmou que Leonardo é usuário de maconha e de cocaína; não conhece Alexandre e não sabe dizer se o seu filho o conhecia. Relatou que seu filho nunca deu trabalho, que é tranquilo, estudou e é educado, mas infelizmente caiu no vício; confirmou que seu filho trabalhou e às vezes ainda trabalha com Isoaldo; disse que seu filho pretende voltar a estudar, fazer cursos, que gosta de mecânica. Disse que, no final de semana dos fatos, ela estava trabalhando no hospital na parte da noite e deixou dinheiro com Leonardo para que ele pudesse comprar um lanche.

A Defesa de ALEXANDRE desistiu da oitiva da testemunha Maria Célia Muriana Rodrigues, e a Defesa de LEONARDO desistiu da oitiva da testemunha Rogério Emydio dos Santos.

Em seu interrogatório, ALEXANDRE negou a acusação, afirmando que não conhecia Leonardo, apenas de vista e através de redes sociais. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou na parte da manhã e à noite veio até José Bonifácio para conversar com sua esposa, com a qual havia brigado no começo da semana; ao chegar na casa da irmã de sua esposa, elas não estavam porque haviam ido para o rancho; ligou para sua esposa e não quis ir até o rancho porque eles haviam discutido e ela estava em família; veio com sua mãe para José Bonifácio e ficou na casa de sua irmã; pediu para sua mãe levá-lo até a casa de Jeferson, de quem é amigo faz tempo, e então eles foram até a praça, comeram um lanche e foram dar uma volta na avenida; voltaram para a praça e pensou em pedir mais um lanche para ir embora; enquanto aguardava o lanche ficar pronto, estava bebendo um refrigerante no quiosque, quando avistou a polícia que o chamou para ir em direção a ela. Como pensou que seria uma abordagem normal, colocou o refrigerante na mesa e foi até os policiais; contou que um deles deu um soco em seu peito e falou que ele estava preso; quando foi responder, Leonardo, que estava próximo e também sendo abordado, saiu correndo, momento em que os policiais colocaram Alexandre na viatura e saíram atrás dele, que foi pego na casa de alguém que acreditava ser o tio dele. Depois que Leonardo foi pego, colocaram-no na viatura junto com Alexandre; perguntaram a este se a droga era dele e ele negou; perguntaram onde ele morava e ele disse; os dois foram conduzidos à delegacia; quando lá chegaram, seus familiares já estavam lá, pois Jeferson os avisara que ele havia sido preso. Disse que na delegacia lhes fizeram várias perguntas; respondeu que não conhecia o outro rapaz. Negou que a droga fosse sua e disse não saber de quem era; os policiais lhe disseram que pegaram as drogas perto de onde ele estava, mas que ele estava num corredor, na porta do lanche, onde muita gente passava. Disse que não dispensou droga, que nem tinha visto a polícia chegar; quando a viu, a viatura já estava estacionada e os policiais o estavam chamando. Disse que frequenta bem pouco José Bonifácio, que não sabia que o local era conhecido como ponto de tráfico; que já teve problema com drogas, por ser usuário, mas que desde quando teve problema criminal anteriormente parou de fazer uso e constituiu família. Afirmou que trabalha com pesca profissional, tem esposa e dois filhos; é casado desde 2014 e mora na Vila dos Pescadores, em Ubarana. Afirmou que vem de vez em quando a José Bonifácio porque suas irmãs moram na cidade. Relatou que havia recebido, no dia anterior, R\$ 400,00 de Francisco, que é comprador de peixe.

Em seu interrogatório, LEONARDO negou a acusação, afirmando que havia pego toda a droga para usar, não para vender. Disse que haveria um baile nesse dia e que, por isso, comprou a droga e depois foi até o lanche da Célia para comer; quando viu os policiais, jogou a droga no mato e sentou no lanche; os policiais, então, deram início à abordagem. Disse que não usaria toda a droga sozinho, mas a dividiria com seus colegas; disse que, de onde os policiais vieram, não dava para ver exatamente a droga, mas que foi ele quem a dispensou, e não Alexandre. Afirmou que não era amigo de Alexandre, que nem o conhecia; que nunca vendeu drogas, só é usuário; que havia comprado na praça mesmo, de um "moreninho alto" que também não conhece; não comprava sempre dessa mesma pessoa, pois cada hora havia uma pessoa diferente no local. Disse que, na delegacia, alegou que apenas a maconha era sua pois ficou com

medo de ser preso caso dissesse que também era o dono da cocaína, mas que foi preso do mesmo jeito. Disse que, no momento da abordagem, ele estava sentado em uma mesa e Alexandre estava lá onde são feitos os pagamentos no quiosque de lanche, e que um policial o abordou em um canto e outro abordou Alexandre em outro canto, do outro lado do lanche.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Conforme os policiais militares ouvidos como testemunha, durante patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico, avistaram os acusados em atitude suspeita e deram início à abordagem; um deles, ALEXANDRE, teria dispensado um pacote ao ver os policiais, enquanto LEONARDO teria corrido. Próximo a ALEXANDRE, encontraram um pacote contendo 20 pinos de cocaína e 6 invólucros contendo maconha, além de encontrarem com o acusado R\$ 370,00 em dinheiro. LEONARDO, que havia corrido, foi capturado posteriormente e com ele foram apreendidos R\$ 31,00 em espécie.

Embora não tenha sido encontrada droga com LEONARDO, este, em seu interrogatório, confirmou que a droga era sua – tanto a maconha quanto a cocaína. Aliás, nesse ponto, o depoimento do acusado LEONARDO diverge da versão apresentada na delegacia, ocasião na qual ele havia dito que portava apenas as porções de maconha e as dispensou no mato quando avistou os policiais. De todo modo, os policiais foram seguros ao dizer que encontraram um pacote contendo tanto a maconha quanto a cocaína.

O policial Renan, em juízo, confirmou que foi ALEXANDRE quem dispensou a droga, e não LEONARDO.

Vale dizer que o simples fato de as testemunhas serem policiais militares, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios. A esse respeito, a jurisprudência é remansosa:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar os acusados falsamente, mesmo porque os policiais não os conheciam.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexistente presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelos acusados precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-los, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Embora a testemunha Francisco tenha afirmado que, na semana dos fatos, pagou a ALEXANDRE R\$ 400,00 referentes à compra de peixe – o que, em tese, poderia justificar os R\$ 370,00 em dinheiro encontrados com o acusado –, não há explicação plausível para a droga apreendida, uma vez que o próprio acusado afirmou que, desde que fora acusado anteriormente por tráfico de drogas, não mais faz uso de qualquer entorpecente.

O acusado LEONARDO confirmou que comprou a droga, de "um moreninho alto", porém afirmou que não seria para venda e sim para consumo próprio "e de seus colegas" num baile que haveria no mesmo dia.

Diferentemente do alegado por ALEXANDRE em seu interrogatório, ele não foi

absolvido por tráfico de drogas em processo anterior, mas condenado (fls. 671/373). Tal fato, juntamente com a droga apreendida nestes autos, sugere que o acusado faz do tráfico o seu meio de vida.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Isso porque o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 caracteriza-se como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali descritas, dentre elas a de trazer drogas consigo, sem autorização, como descrito na denúncia.

Logo, resta bem caracterizada a conduta delitiva.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

I- Quanto a LEONARDO

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário (fls. 669/670).

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, visto que o acusado nasceu em 23/06/1998 (art. 65, I, do CP), mas ela não repercute na dosimetria, uma vez que a pena se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Consequentemente sua pena não se altera.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistem indicativos de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor: “Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa” (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Logo, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena.

Pelo montante, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483 das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

II- Quanto a ALEXANDRE

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado para a Defesa em 08/05/2017 (data do fato: 25/11/2013), 29/06/2015 (data do fato: 14/12/2013) e 04/11/2021 (data do fato: 21/12/2015). Não consta extinção da pena (fls. 671/673).

A situação concreta caracteriza multirreincidência, motivo pelo qual as condenações, desde que distintas, podem ser utilizadas tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria:

Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. (AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que, considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência (AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019)

Assim, a primeira condenação mencionada deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ), enquanto as demais devem ser valoradas negativamente como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ainda de acordo com a jurisprudência, "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Diante disso, as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas

a justificarem a exasperação da pena-base.

Conforme a jurisprudência, em regra, é razoável exasperar a pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, porém, é possível aplicar fração superior para a valoração de um único vetor, se preponderante:

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 666.280/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Assim, pela presença de antecedentes, mostra-se proporcional ao caso concreto exasperar a pena em 1/6, o que resulta em: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pelo antecedente mencionado, motivo pelo qual a pena deve ser exasperada em 1/6, o que resulta em: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência afasta a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Logo, torno definitiva a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Deixo de considerar o tempo de prisão preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por entender que tal avaliação compete ao juízo da execução criminal, haja vista que para a progressão de regime é necessária a presença da boa conduta carcerária (art. 112, §1º, da Lei 7.210/84), requisito subjetivo que, por isonomia, deve ser exigido de todos, sentenciados e presos provisórios (art. 387, §2º, do CPP).

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que é reincidente, possui antecedentes e a pena é maior que 4 anos, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar:

I- LEONARDO ROSSI à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06. Com fundamento nos arts. 44, §2º; 43, I e IV; 45 e 46 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade a ele aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução; e

II- ALEXANDRE DE ARAUJO BATISTA à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como efeito da condenação, declaro a perda dos valores apreendidos, por constituírem produto do crime (art. 5º, LIV, da Constituição e art. 91 do CP), os quais deverão ser mantidos em depósito até o trânsito em julgado (arts. 61 a 63 da Lei 11.343/06).

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à

autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

Os acusados respondem ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar. Portanto, fazem eles jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos deverem ficar presos (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspensão" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifacio, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA